

0088722-35.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... transcrevo algumas partes:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0088722-35.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0088722-35.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK PEREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

ERICK PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do art. 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal e art. 244-B, caput da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal, porque, ao que consta, no dia 09 de julho de 2015, em horário incerto, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, altura do nº 5353, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado, menor de 21 anos, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com os adolescentes Roberto Marsola Júnior e Alexandre Maciel Santos, subtraiu, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com um revólver Taurus, calibre.32, numeração suprimida, um aparelho celular Motorola/Moto G, avaliado em R\$ 700,00, pertencente à vítima Cíntia R.L. Consta na denúncia que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes Roberto Marsola Junior e Alexandre Maciel Santos, praticando a infração penal acima descrita. No dia dos fatos, a vítima se dirigia ao trabalho, quando, ao desembarcar do transporte coletivo, foi abordada pelo denunciado e pelos outros dois comparsas, os quais, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular. Após a subtração, todos empreenderam fuga. Policiais militares receberam a notícia da prática de um roubo e avistaram os assaltantes. Na abordagem, foi localizado o celular e a arma utilizada para a prática do delito.

A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2019 (fls. 135/136). Citado (fls. 181/183) o réu apresentou resposta à acusação (fls. 186). A decisão de fls. 196 designou audiência de instrução, debates e julgamento. Na audiência, foram tomados os depoimentos da vítima, testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado. Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório com a condenação do réu. A defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da ação por insuficiência probatória. É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Passo, pois, a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos acusados pela prática dos delitos de roubo qualificado. O pedido é improcedente. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 11/12), boletim de ocorrência (fls. 21/25 e fls. 76/83), bem como pelos depoimentos tomados em juízo. Perante a autoridade policial o réu se reservou ao seu direito constitucional de ficar calado e só se manifestar em juízo. (fls. 19). Em juízo, o réu ERICK afirmou que tem 25 anos e utilizou o direito ao silêncio. A vítima Cintia, reconheceu o réu em juízo e contou que estava indo trabalhar, pegou a lotação sentido Pirituba quando entraram 3 ou 4 pessoas e pediram carona entrando por trás. Estava em um banco mais a frente e depois de 3 pontos desceu e quando chegava na esquina do trabalho eles a abordaram pediram o celular, disseram que só queriam o celular, que não queriam nada da bolsa, o que estava do lado mostrou a arma, e entregou o celular. Entrou no lava rápido e tinha uma viatura no local, contou e indicou onde eles tinham ido que era uma rua sem saída. O policial conseguiu deter os 3. Falaram que só um era de maior e um maior. Mostraram fotos dos 3 na hora e já reconheceu. Hoje em juízo reconheceu com dúvidas o réu. O celular foi recuperado. No dia não prestou depoimento. Depois chegou uma carta na empresa. Não fez reconhecimento no dia na delegacia, somente por foto apenas dos 3. Colocaram as pessoas dentro da viatura e os viu. Os policiais disseram que encontraram os celulares com eles e devolveram lá na empresa. Os policiais falaram que mais 3 pessoas foram assaltadas. A ofendido Alexandre Maciel Santos permaneceu em silêncio. O ofendido Roberto Marsola Júnior também permaneceu em silêncio. A testemunha Leandro Zacarias Pereira, policial militar, afirmou que estavam fazendo patrulhamento quando foram acionados por populares informando que 3 indivíduos estavam roubando celulares nas imediações, os avistaram e conseguiram deter dois deles. Encontrou os celulares que as vítimas reconheceram e seu parceiro encontrou uma arma. Encontraram 2 vítimas, acha que no total eram 3. No DP as vítimas reconheceram o material. Não se recorda do que eles falaram. O policial militar Fabio Juliano Silva, o qual contou que foram roubos a celulares, foi apreendida uma arma. Estavam em patrulhamento pela via quando uma vítima disse que tinha sido roubada e indicou a direção, mais a frente se depararam com uma segunda vítima que passou o destino e as características. Eles foram abordados e na cintura encontraram um revólver. Foram encontrados 3 celulares, de duas vítimas e o terceiro de uma vítima que não compareceu ao DP mas disse que tinha sido roubada. Os celulares apreendidos no dia, da sequência de roubos, foram apresentados no DP. Não sabe se houve outras vítimas e foram devolvidos os celulares. Eles estavam em 3. O depoente que abordou o réu e com ele foi localizado o revólver, não se lembra se estava municiado. O seu parceiro fez a busca pessoal dos outros e localizou os celulares. Não lembra quantos celulares estavam com os outros. Um garoto que estava com o pai e uma moça que trabalhava próximo ao local. A vítima era morena, não era tão magra e tinha cabelo curtinho. Ela fez o reconhecimento do celular e depois na delegacia fez o reconhecimento pessoal. Verifica-se pelo relato da vítima que o seu celular foi restituído logo após o ocorrido sendo que não lhe foi solicitado que comparecesse à delegacia ou fizesse

qualquer reconhecimento. Disse ainda que foi anoite na delegacia mas seus relatos não foram tomados.

Já os policiais narram que a vítima foi à delegacia e fez o reconhecimento.

A investigação foi permeada de diversas inconsistências, dado que a vítima afirmou que o reconhecimento fotográfico se deu dois anos depois dos fatos com as fotos do réu e dos adolescentes e não de outras pessoas, sendo que em juízo ela novamente viu os 3 e reconheceu com bastante dúvida apenas o réu, que diga-se, já tinha sido vista nas fotos anteriormente mostradas.

Ressalte-se que, nesta data a vítima viu os dois adolescentes que estariam juntos e eles ela não reconheceu fragilizando ainda mais a prova dos feitos.

O policial Leandro ainda afirmou que a vítima descrita como Cintia teria ido na delegacia e feito reconhecimento bem como recuperado seu celular, o contrário do dito pela própria ofendida.

Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelo ofendido em juízo, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório.

Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender

geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização. (MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Se não bastasse isso, sem qualquer motivo aparente o boletim de ocorrência foi lavrado constando as duas vítimas (Alexsander e Cintia) contudo, sem a oitiva da Cintia ou reconhecimento formal (fls. 21/25) que apenas se deu dois anos após os fatos (fls. 92), quando o réu já havia cumprido grande parte da sua pena e poderia inclusive ser levado para o reconhecimento pessoal, prejudicando assim o oferecimento da denúncia que ocorreu separadamente para as vítimas e delitos.

Fica claro portanto que, caso a autoridade policial tivesse cumprido seu dever e realizado todas as diligências na oportunidade, o que não ocorreu pois a vítima disse que foi ao no dia dos fatos e não foi ouvida, o réu seria denunciado pelos delitos cometidos em poucos minutos na mesma avenida em continuidade delitiva até porque o boletim de ocorrência foi feito para as duas vítimas e não separadamente. Ora, condenar o réu, depois de cumprida toda a sua pena pelos roubos feitos no mesmo local seria um verdadeiro bis in idem em prejuízo absurdo do réu por um erro do estado, até porque naquela oportunidade teria sua pena no máximo sido aumentada em 1/6 enquanto no presente processo poderia ser condenado a pena superior a 6 anos, em completo descompasso legal e irrazoável e em afronta ao princípio educativo e racional da pena.

Os fatos se deram em 2015, o policial descreveu a vítima Cintia como uma das que as abordou bem como ela disse que recuperou o celular no dia dos fatos, não havendo qualquer justificativa para que ela não fosse ouvida e o processo permanecesse parado por tanto tempo.

Ademais, após os fatos, o réu ficou preso exatamente pelos crimes cometidos em sequência, tendo sido solto em julho de 2017 (fl. 129) não havendo notícias de que tenha cometido qualquer infração até a presente data, mostrando-se reintegrado socialmente, sendo um contrassenso determinar a prisão do réu por crime que já respondeu há mais de 5 anos atrás.

Há de se ressaltar nesta toada que, ainda quanto ao delito de corrupção de menores seria impossível condena-lo novamente pelos fatos sendo que os supostos roubos e a corrupção se deram nas mesmas oportunidades, não havendo razão para considerar que os adolescentes tenham sido corrompidos ao longo do caminho da rua.

Os fatos de ambos os processos são substancialmente os mesmos, e somente por uma questão prática, por ocasião de conveniência ou inconveniência, dado a ausência completa de justificativa para que a vítima não tenha sido ouvida no dia dos fatos, o presente roubo não ingressou naqueles autos.

O roubo desse único celular, se comprovado, não alteraria a realidade processual do outro feito, proporcionalmente falando pois como dito no máximo majoraria a pena em 1/6.

Uma questão de deficiência do Estado ou atraso do serviço público não pode prejudicar o réu.

Assim, seja pela maculação da prova, ante ao reconhecimento fotográfico realizado

dois anos após os fatos apenas com a fotografia do réu e dos adolescentes seja pelo completo descaso com o andamento processual que levou a uma denúncia posterior que geraria pena irrazoável ferindo o bis in idem e a proporcionalidade das sanções a absolvição é medida que se impõe.

Isto posto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu ERICK PEREIRA DE OLIVEIRA da imputação que lhe foi atribuída, com fundamento no art. 397, inc. IV do Código de Processo Penal. Sem condenação a custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA